

刑法
No.41

H18-8

(配点：2)

月 日

月 日

故意に関する次の【見解】を採って後記1から5までの各記述を検討した場合、正しいものはどれか。

【見 解】

「故意を認めるためには犯罪事実の認識が必要であるが、行為者が認識した犯罪事実と現実に発生した犯罪事実が異なっても、両者が法定の範囲内において重なり合う限度で、軽い犯罪の故意を認めることができる。」

1. 甲が誤ってVに重大な傷害を負わせたところ、Vと全く関係のない乙が、甲と何ら意思の連絡なく、まだ生きているVを既に死亡したものと思って遺棄した場合、乙について死体遺棄罪の成立を肯定することができる。
2. 甲が殺意をもってV1をねらいけん銃を発射したところ、V1に命中した弾丸が更にV2にも当たり、V1及びV2が死亡した場合、V1に結果が発生した以上、V2に対する殺人罪の成立を肯定する余地はない。
3. 甲が殺意をもってVをねらいけん銃を発射したところ、甲は弾丸を頭部に命中させて即死させるつもりだったが、頭部には命中せずにVの下腿部に当たって受傷させ、搬送先の病院で死亡させた場合、殺人罪の成立は否定される。
4. 甲が殺意をもってVをねらいけん銃を発射したところ、弾丸はVに命中せずにVが散歩中に連れていたVの犬に当たって死なせた場合、器物損壊罪の成立は否定される。
5. 甲が乙に対しV宅に空き巣に入るように唆したところ、乙はV宅の戸締まりが厳重であったために空き巣に入ることをあきらめて帰宅したが、その途中、乙は、自宅近くでたまたま入ったコンビニエンスストアで急に空腹を覚え、自分で食べるためにパンを万引きした場合、甲について窃盗（既遂）教唆罪の成立を肯定することができる。

No.41	事実の錯誤	正答率
H18-8	正解 4	82%

設問の見解は、構成要件の範囲内で、主観と客観が一致することを要求する「法定的符合説」である。

1 誤っている

Vと全く関係のない乙は、まだ生きているVを既に死亡したものと思って遺棄したのであるから、乙は、死体遺棄罪（190条）の故意で、単純遺棄罪（217条）を犯したことになる。法定的符合説によれば、異なった構成要件間における錯誤の場合には、原則として故意は阻却される。もっとも、異なる構成要件間であっても、両者の保護法益及び構成要件の行為の共通性が見出される場合には、両者の重なり合いを認めることができ、軽い犯罪の故意を認めることができると解されている（実質的符合説）。そして、構成要件は違法行為類型であるから、保護法益の共通性は構成要件の重なり合いが認められるための最低限度の要件であると解されている。この点、死体遺棄罪は国民の広い意味の宗教感情を保護法益とし、単純遺棄罪は個人の生命・身体を保護法益とするので、両者の保護法益の共通性は認められない。よって、実質的符合説によっても、乙に死体遺棄罪は成立せず、乙の行為は、死体遺棄罪の未遂又は不能犯、及び過失による遺棄として不可罰となる。

2 誤っている

甲が殺意をもってV1をねらいけん銃を発射したところ、V1に命中した弾丸が更にV2にも当たり、V1及びV2が死亡した場合、甲は1個の殺人の故意で、2個の殺人の結果を生じさせたといえ、故意の個数が問題となる。この場合、故意の責任を認める前提としての故意は「人を殺す」ことについての認識があれば足りるから、その点に関する限り殺される人の数は重要でなく、その数はいくらでも責任の量において考慮されるべきであるとする立場（数故意犯説）を採れば、法定的符合説からも、V1だけでなくV2に対しても殺人罪（199条）の成立を肯定し得る。

3 誤っている

甲が殺意をもってVをねらいけん銃を発射したところ、甲が予期したところ（「弾丸を頭部に命中させて即死させる」）と異なった因果関係の経過（「頭部には命中せずにVの下腿部に当たって受傷させ、搬送先の病院で死亡させた」）をたどって予期した結果が発生しているので、因果関係の錯誤が問題となる。そして、行為者の予見した因果の経過と現実の因果の経過とが相当因果関係の範囲内で符合している限り、故意は阻却されないという見解を採ると、法定的符合説からは、行為者甲の予見した「弾丸を頭部に命中させて即死させる」という因果の経過は相当因果関係の範囲内にあり、現実の「頭部には命中せずにVの下腿部に当たって受傷させ、搬送先の病院で死亡させた」という因果の経過も相当因果関係の範囲内にあるから、両者は相当因果関係の範囲内で符合しており、甲には殺人罪の故意が認められる。他方、因果関係の認識不要説を採ると、因果関係の錯誤は故意を阻却しないため、甲には殺人罪の故意が認められる。

4 正しい

甲が殺意をもってVをねらいけん銃を発射したところ、弾丸はVに命中せずにVが散歩中に連れていたVの犬に当たって死なせたのであるから、甲は、殺人罪の故意で、器物損壊罪（261条）を犯したことになる。記述1で述べたとおり、異なる構成要件間であっても、両者の保護法益及び構成要件の行為の共通性が見出される場合には、両者の重なり合いを認めることができ、軽い犯罪の故意が認められると解されている（実質的符合説）。そして、保護法益の共通性は構成要件の重なり合いが認められるための最低限度の要件であると解されている。この点、殺人罪は個人の生命を

保護法益とし、器物損壊罪は他人の財物を保護法益とするので、両者の保護法益の共通性は認められない。よって、実質的符合説によっても、甲に器物損壊罪の故意は認められず、甲は、Vについては危険の発生を条件に殺人未遂罪（203条、199条）となり、犬については過失による器物損壊であり不可罰となる。

5 誤っている

まず、V宅への空き巣の点については、乙が実行に着手すらしていないから、教唆者たる甲にも犯罪は成立しない。次に、コンビニエンスストアでの万引きの点については、「乙はV宅の戸締まりが厳重であったために空き巣に入ることをあきらめて帰宅したが、その途中、乙は、自宅近くでたまたま入ったコンビニエンスストアで急に空腹を覚え、自分で食べるためにパンを万引きした」のであり、乙はコンビニエンスストアで新たに窃盗の犯意を生じたといえ、甲の教唆と乙の窃盗との因果性が否定される。そのため、錯誤についてどのような見解に立つかにかかわらず、甲について窃盗（既遂）教唆罪は成立しない。